

第56問

甲は、未成年者Aの母Bの母であるところ、Bが死亡したことを機に、C家庭裁判所家事審判官によりAの未成年後見人に選任され、以後、Aの預貯金の出納、保管等の業務に従事していた。

ある日、甲は、甲の弟である乙から「Aの面倒を見るのは大変だろう。Bは、生前、かなりの蓄えがあったようだから、少しくらいいただいてもバチは当たらないと思う。」などと提案を受けた。甲は、乙の言うとおりでと思うとともに、乙が近所に住んでいることもあって、日頃からAのことをかわいがってくれていたため、「それなら、私とあなたで200万円ずつもらいましょう。」などと言い、管理していたAの口座から400万円を引き出し、乙に200万円を交付し、残りは自己の用途のために費消した。

甲及び乙の罪責について、論じなさい。

最決平20.2.18【百選Ⅱ35】を素材とする問題である（以下「素材判例」という。）。

第1 甲の罪責

- 1 甲は、後見の事務としてAの預貯金を預かっているため、社会生活上の身分に基づいて、反復継続して行われる事務として占有しているため、業務上横領罪（253）に当たる。なお、預金による占有が認められる点についても一言触れておくとい（大判大9.3.12）。
- 2 甲は、Aの祖母に当たるため、「直系血族」として、255条が準用する244条1項の適用（準用）があり、刑が免除されるのではないかが問題となる（**論点** 横領罪と親族間の特例）。

総合 245 頁 論証 118 頁

この点について、素材判例は、「刑法255条が準用する同法244条1項は、親族間の一定の財産犯罪については、国家が刑罰権の行使を差し控え、親族間の自律にゆだねる方が望ましいという政策的な考慮に基づき、その犯人の処罰につき特例を設けたにすぎず、その犯罪の成立を否定したものではない」

「家庭裁判所から選任された未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが（民法859条1項）、その権限の行使に当たっては、未成年被後見人と親族関係にあるか否かを問わず、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負い（同法869条、644条）、家庭裁判所の監督を受ける（同法863条）。また、家庭裁判所は、未成年後見人に不正な行為等後見の任務に適しない事由があるときは、職権でもこれを解任することができる（同法846条）。このように、民法上、未成年後見人は、未成年被後見人と親族関係にあるか否かの区別なく、等しく未成年被後見人のためにその財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っていることは明らかである。

そうすると、未成年後見人の後見の事務は公的性格を有するものであって、家庭裁判所から選任された未成年後見人が、業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合に、上記のような趣旨で定められた刑法244条1項を準用して刑法上の処罰を免れるものと解する余地はない」として、適用を否定した。

第2 乙の罪責

業務上横領罪の共同正犯を検討することになる。甲及び乙には十分な意思連絡が認められること、乙が甲に犯意を生じさせていること、横領金の半額を受け取っていることから、正犯性が認められることは明らかである。

乙は未成年後見人ではないから、いわゆる共犯と身分の問題を論じることになる（**論点** 業務上横領と共犯 **論** 司H21,H24,予H27,旧H1-2）。判例（最判昭32.11.19【百選Ⅰ94】）は、「刑法65条1項により同法253条に該当する業務上横領罪の共同正犯として論ずべきものである。しかし、同法253条は横領罪の犯人が業務上物を占有する場合において、とくに重い刑を科することを規定したものであるから、業務上物の占有者たる身分のない被告人両名に対しては同法65条2項により同法252条1項の

総合 246 頁 論証 119 頁

通常の横領罪の刑を科すべきものである」として、業務上横領罪の共犯が成立すると解しつつ、科刑は単純横領罪（252 I）のそれによっている。

答案構成

第1 甲の罪責

1 業務上横領罪（253）の成否

↓

2 「業務」とは、反復継続して行われる事務であって、他人物の占有が業務内容になっているものをいう

↓

あてはめ

↓

「占有」とは、濫用のおそれのある支配力を指し、事実的支配のみならず、法律的支配も含む

↓

預金による占有も「占有」に当たる

↓

委託信任関係、「横領」

↓

業務上横領罪成立

↓

3 244条1項適用（準用）の可否

↓

否定説

↓

4 業務上横領罪が成立し、刑の免除は認められない

第2 乙の罪責

1 業務上横領罪の共同正犯（60）の成否

↓

実行行為を担当していないことは障害とならない

↓

2 共犯と身分

↓

65条1項は真正身分犯、同条2項は不真正身分犯の規定

↓

業務上横領罪は真正身分犯であるから、65条1項により、同罪の共同正犯が成立する

↓

科刑は単純横領罪（252 I）のそれによる

↓

3 乙は業務上横領罪の共同正犯の罪責を負うが、その刑は単純横領罪を基準とする

第1 甲の罪責

1 甲が管理していたAの口座から400万円を引き出し、乙に200万円を交付し、残りは自己の用途のために消費した行為について、業務上横領罪（253条）の成否を検討する。

2(1) まず、「業務」とは、社会生活上の身分に基づいて、反復継続して行われる事務であって、他人物の占有が業務内容になっているものを指す。

甲は、C家庭裁判所家事審判官により選任されたAの未成年後見人であり、Aの預貯金の出納、保管等の業務に従事していたのであるから、反復継続して行われる事務であって、他人物の占有が業務内容になっているものといえ、「業務」に当たる。

(2) また、「占有」とは、濫用のおそれのある支配力を指し、事実的支配のみならず、法律的支配も含むから、Aの口座の預貯金は、甲の法律的支配に属するものとして、「自己の占有する他人の物」に当たる。甲は、法令に基づいて後見人としてAの財産を管理しているのであるから、委託信任関係も認められる。

そして、Aの口座の預貯金を引き出して乙に交付し、又は自己の用途のために消費した行為は、不法領得の意思の発現たる「横領」行為に当たる。

故意（38条1項）に欠けるところもない。

(3) 以上より、甲の上記行為に、業務上横領罪が成立する。

3 もっとも、甲は、Aの祖母に当たるため、直系血族との間で業務上横

1

領罪が行われたことになる。そこで、親族間の特例255条が準用する244条1項を適用することはできないか。

同条の趣旨は、家庭内の問題は法が介入せず自主的に解決させることが妥当であるとの政策的考慮にある。

この点について、後見人は、民法上、被後見人と親族関係にあるか否かの区別なく、被後見人のためにその財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っており、そのような事務は公的性格を有するというべきである。

そうだとすれば、上記のような政策的考慮が妥当する余地はなく、親族間の特例を適用することはできないと解すべきである。

4 以上より、甲に業務上横領罪が成立し、刑の免除も認められない。なお、後述のように、乙とは共同正犯（60条）となる。

第2 乙の罪責

1 乙は、甲に対して、「少しくらいいただいてもバチは当たらないと思う。」などと言って、意を通じてAの口座から400万円を引き出し、横領金の半分を受け取っているため、「共同して犯罪を実行した」として、業務上横領罪の共同正犯が成立する可能性がある。なお、乙は、実行行為を行っていないが、共同正犯の処罰根拠である共同犯行の一体性が認められる限り、共同正犯とすることに支障はない。

2(1) とはいえ、業務上横領罪は、「業務上……の占有」を主体とする身分犯であるから、65条が適用される。

(2) 65条1項は「身分によって構成すべき犯罪」、同条2項は「身分

2

によって特に刑に軽重があるとき」としている。このような文言に着目し、1項は真正身分犯の規定であり、2項は不真正身分犯の規定であるというべきである。

- (3) ここで、非占有者からすると、業務上の占有者であることは真正身分であるから、65条1項で業務上横領罪が成立するというべきである。そして、身分なきものも身分者を通じて身分犯の法益侵害結果又はその危険を惹起することができるから、「共犯」には、共同正犯を含む。

したがって、乙には、65条1項により、業務上横領罪の共同正犯が成立する。

- (4) しかし、単なる占有者が業務上物を占有する者と共犯行為を行った場合、65条2項で単純横領が成立することとの均衡を欠くおそれがある。

そこで、処断刑は単純横領罪（252条1項）を基準にすべきであると考える。

- 3 よって、乙は業務上横領罪の共同正犯の罪責を負うが、その刑は単純横領罪を基準とする。

以上